

1501699-57.2022.8.26.0526

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: ALVARO AMORIM DOURADO LAVINSKY

Comarca: Salto

Foro: Foro de Salto

Vara: 3ª Vara

Data de Disponibilização: 22/11/2022

... CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DA IMPUTAÇÃO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PROVA INSUFICIENTE DA ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA DO VÍNCULO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO INVIÁVEL. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. APLICAÇÃO IMPOSSÍVEL. DEDICAÇÃO DOS PACIENTES À ATIVIDADE ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Salto

Foro de Salto

3ª Vara

Av. Dom Pedro II, 261, Salto-SP - cep 13320-240

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501699-57.2022.8.26.0526 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501699-57.2022.8.26.0526

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2167816/2022 - DEL.POL.PLANTÃO SALTO, 25674474 -

DEL.POL.PLANTÃO SALTO, 2167816 - DEL.POL.SALTO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

AMANDA DOS SANTOS RIBEIRO e outros

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ALVARO AMORIM DOURADO LAVINSKY

Vistos.

Trata-se de ação penal movida pelo Ministério Público contra os réus JOACIR DA SILVA RIBEIRO, GABRIEL DOS SANTOS e AMANDA DOS SANTOS RIBEIRO, qualificados nos autos, como incurso no artigo 33, caput, e artigo 35, caput, ambos da Lei nº 11.343/06, na forma do artigo 69, do Código Penal, porque em tese, em dia e local indeterminados, mas através de condutas que perduraram até 21 de junho de 2022, por volta das 13h13min, na Rua Acácio Rodrigues de Moraes, nº 675, Jardim Saltense, nesta cidade e comarca de Salto/SP, associaram-se para o fim de praticar, reiteradamente ou não, tráfico ilegal de drogas.

Consta ainda que, no dia 21 de junho de 2022, por volta das 13h13min, na Rua Acácio Rodrigues de Moraes, nº 675, Jardim Saltense, nesta cidade e comarca de Salto/SP, os acusados, agindo em concurso, previamente associados e em unidade de desígnios,

guardavam, traziam consigo e tinham em depósito, para entrega a consumo e fornecimento, ainda que gratuito: a) 19 (dezenove) porções de “crack”, com peso aproximado de 9,15g (nove gramas e quinze decigramas); b) 53 (cinquenta e três) porções de “cocaína”, com peso aproximado de 80,61g (oitenta gramas e sessenta e um decigramas); c) 201 (duzentas e uma) porções de “maconha”, com peso aproximado de 592,02g (quinhentos e noventa e dois gramas e dois centigramas), tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Os acusados foram presos em flagrante e, em audiência de custódia, as prisões foram convertidas em prisões preventivas (fls. 46-50).

Os réus foram notificados pessoalmente e apresentaram defesas prévias (fls. 111-119, 141-150 e 152-157).

A denúncia (fls. 72-78) foi recebida em 03 de outubro de 2022 (fls. 172-176).

Em fase de instrução processual foram inquiridas testemunhas arroladas pela acusação, pela defesa e os réus foram interrogados.

As preliminares de ilegalidade da prisão em flagrante por guardas municipais, invasão de domicílio e ilicitude de prova, foram apreciadas e rejeitadas pela decisão de fls. 172-176, que transitou em julgado.

Em alegações finais, o representante do Ministério Público requereu a condenação dos acusados nos termos da denúncia. A Defesa de AMANDA DOS SANTOS RIBEIRO requereu a decretação de nulidade decorrente da atuação dos guardas municipais, a busca localizada na residência, a investigação de dados existentes no celular de Amanda por parte dos guardas municipais. No mérito requereu a absolvição da acusação pelo crime de tráfico e de associação criminosa por ausência de provas.

Alternativamente, requereu a aplicação da pena no mínimo legal e fixação de regime compatível, menos gravoso. A Defesa de JOACIR DA SILVA RIBEIRO requereu a decretação de nulidade decorrente da atuação dos guardas municipais na busca pessoal realizada em Joacir e busca localizada na residência sem autorização. No mérito requereu a absolvição da acusação pelo crime de associação criminosa por ausência de provas. Alternativamente, requereu a aplicação da pena no mínimo legal e aplicação de regime menos grave.. A Defesa de GABRIEL DOS SANTOS pleiteou a absolvição por ausência de provas ou alternativamente a fixação de pena mínima.

É o relatório do essencial.

Fundamento e decido.

Rejeito as preliminares de nulidades suscitadas pelas Defesas no tocante à atuação dos guardas municipais, no que tange à abordagem pessoal do acusado Joacir, busca domiciliar e investigação de dados existentes no celular de Amanda.

O tráfico é crime permanente, portanto, nos termos do artigo 301 do Código de Processo Penal, qualquer pessoa pode prender quem esteja em flagrante delito. Havia justa causa para a abordagem de Jovair, que estaria, segundo denúncia formulada à Central da Guarda Municipal de Salto, traficando em via pública, sendo repassada aos guardas as características físicas de Jovair, que realmente portava droga na ocasião, conforme será pormenorizado abaixo, ou seja, tudo sem que houvesse qualquer procedimento investigativo prévio..

Ademais, os réus Amanda e Gabriel disseram nos respectivos interrogatórios que autorizaram a entrada dos guardas na residência, na qual foi localizada grande quantidade de entorpecentes. Embora Joacir negue ter autorizado a entrada dos guardas na casa, o seu enteado Gabriel afirmou que Joacir também autorizou a entrada da guarda.

Em relação ao uso de dados existentes no celular da acusada Amanda por parte dos guardas municipais, tal afirmação não restou minimamente provada, sendo ônus da Defesa a prova de tal alegação. A respeito do ônus da prova por parte do acusado, confira-se a afirmação de Guilherme de Souza Nucci in Provas no Processo Penal (2015; p.35):

"Ao réu, se pretende apenas negar a imputação, resta permanecer inerte, pois nenhum ônus lhe cabe. Seu estado de inocência prevalece. Entretanto, se a estratégia de defesa tiver por meta alegar fato diferenciado daqueles constantes da denúncia ou queixa, chama a si o ônus da prova. É o que, naturalmente, ocorre com a sustentação do alibi (dizer que estava em local diverso daquele onde aconteceu o crime).

Buscará o acusado, por interesse seu, demonstrar ao juiz a autenticidade de sua

informação. Cabe-lhe o encargo, a responsabilidade. Não demonstrado o álibi, permanece o réu na sua condição de inocente, mas, provavelmente, a acusação conseguirá avançar, ainda mais, na sua linha de demonstração de que ele é culpado."

De qualquer maneira, não foram considerados como prova dados de aparelho celular obtidos pela guarda municipal e sim pela polícia civil, conforme laudo de extração de dados (fls. 222-379), não havendo prejuízo à Defesa no particular, devendo ser observado o artigo 157, § 2º, do Código de Processo Penal.

Nesse contexto, inexistente óbice à atuação dos guardas municipais, não havendo, portanto, que se cogitar em nulidade no caso em tela. Na mesma linha de entendimento, tem-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

"PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. NULIDADE PELA ATUAÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL. INOCORRÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS QUE LEGITIMAM A AUTUAÇÃO DA REFERIDA ENTIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 301 DO CPP. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA BASILAR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRETENSÃO DE INCIDÊNCIA DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. INOVAÇÃO RECURSAL EM SEDE DE AGRAVO REGIMENTAL. NÃO ENFRENTAMENTO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ENUNCIADO SUMULAR N. 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. I - Nos termos da jurisprudência consolidada nesta Corte, cumpre ao agravante impugnar especificamente os fundamentos estabelecidos na decisão agravada. II - Inicialmente, no que se refere à pretensão de reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado, verifico tratar-se de inovação recursal em sede de agravo regimental, uma vez que tal pretensão não foi feita na inicial do writ, o que não é admitido pela jurisprudência. Ademais, ainda que assim não fosse, a reincidência do agravante obsta a concessão da benesse, não havendo que se falar em bis in idem. Precedentes. III - No que se refere à preliminar de nulidade pela atuação da guarda municipal, verifica-se que a Corte de origem invocou fundamentos para refutar a referida alegação que estão em sintonia com o entendimento deste Tribunal que, embora ressalte ser descabida a realização de investigações de práticas de ilícitos, disso não se desume a possibilidade de, mediante notícia de crime, proceder a diligências de averiguação, haja vista a possibilidade de prisão em flagrante, como ocorreu no presente caso. Com efeito, como bem observado pela Corte de origem, "os Guardas Municipais, assim como qualquer outra pessoa do povo, ao contrário do entendido externado pela nobre Defesa, pode deter alguém pela prática de crime, desde que em flagrante delito" (fl. 88), não havendo que se falar em nulidade por este fundamento. Precedentes. IV - Outrossim, descabida a alegação de que a basilar foi aumentada de forma inidônea, haja vista que a sentença condenatória levou em consideração a natureza, quantidade e diversidade das drogas apreendidas, tratando-se de "04 porções de maconha, com peso líquido de 0,74g; 50 porções de maconha, com peso líquido de 105,98g; 23 porções de cocaína, com peso líquido de 11,93g; 23 porções de cocaína, com peso líquido de 15,2g; e 31 porções de cocaína sob a forma de crack, com peso líquido de 5,02g" (fl. 46), aplicando a fração de 1/6 (um sexto), tudo de acordo com o entendimento deste Tribunal. Precedentes. V - In casu, a Defesa limitou-se a reprisar os argumentos do habeas corpus, o que atrai o Enunciado Sumular n. 182 desta Corte Superior de Justiça, segundo a qual é inviável o agravo regimental que não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. (AgRg no HC n. 748.762/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 23/8/2022.)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. FLAGRANTE POR GUARDAS MUNICIPAIS. ILEGALIDADE NÃO RECONHECIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Conforme jurisprudência consolidada desta Corte Superior, não há falar em ilegalidade na prisão em flagrante realizada por guardas civis municipais. Consoante disposto no art. 301 do CPP, "qualquer do povo poderá e as autoridades policiais e seus agentes deverão prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito". Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 748.019/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022.) A pretensão punitiva estatal merece parcial procedência.

A materialidade do delito de tráfico de drogas restou comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01), boletim de ocorrência (fls.02-05), auto de exibição e apreensão (fls. 08-09), auto de constatação preliminar de substância entorpecente (fls. 10), laudo de exame químico toxicológico (fls.88-91), laudo pericial em peças (fls. 106-109), laudo de extração de dados (fls. 222-379), tudo em harmonia com a prova oral coligida nos autos.

A autoria do delito também é certa.

Os guardas municipais Marcelo D'Amico Lenham e Lovejoi Pereira Modesto, testemunhas comuns, relataram, em resumo, que receberam via controle a informação de que na rua Acácio Rodrigues de Moraes, havia um homem de muletas efetuando a venda de drogas pelo local e que pegava as drogas em sua residência e as vendia na via pública em pequenas porções. No local indicado, encontraram o acusado Joacir, o qual apresentava as características da denúncia, razão pela qual realizaram abordagem pessoal. Com Joacir foram encontradas 02 porções de maconha e a quantia de R\$20,00. Questionado, revelou que havia mais entorpecentes em sua residência, franqueando a entrada. Viram Gabriel, nos fundos, com uma sacola plástica preta, tendo ele dispensado a sacola no chão. Gabriel e Amanda foram na direção depoentes. Com a permissão de todos adentraram à residência. Questionaram Gabriel sobre a existência de mais drogas pela casa este negou haver, perguntaram também a Amanda, que inicialmente também negou. Encontraram no quarto de Joacir mais 03 porções de maconha. Procederam com buscas pelos demais cômodos. Amanda informou ter mais drogas no lixo do banheiro, local onde encontraram mais 03 pacotes contendo diversas porções de maconha em cada um deles. No fundos da residência, onde Gabriel foi visto dispensando uma sacola, foram localizados, no interior da mencionada sacola, 03 pacotes com diversas porções de maconha, 19 porções de crack, 53 de cocaína e a quantia de R\$230,00. Na cozinha, localizaram 02 balanças, 02 rolos de filme plástico e uma faca desgastada. No quarto de Joacir, encontraram 1 par de radiotransmissores, do tipo usado pelas forças policiais.

A testemunha de defesa, Luana Gonçalves de Abreu, em Juízo, disse que é esposa de Gabriel, sendo ouvida sem prestar compromisso. Disse que Gabriel estava no local dos fatos porque foi alimentar um cachorro.

A ré Amanda dos Santos Ribeiro, interrogada judicialmente, disse que não sabia que existia droga na residência. Autorizou a entrada dos guardas. Não sabe de quem era a droga encontrada na casa. Desbloqueou o celular e passou para os guardas municipais.

O réu Joacir da Silva Ribeiro, interrogado, respondeu que foi abordado pelos guardas municipais na rua. A maconha que estava com ele era destinada ao seu uso, ia receber essa droga em decorrência de uma dívida. A droga que estava na casa, localizada pelos guardas, era sua, destinada ao tráfico, porque passava por necessidades financeiras. A filha Amanda não sabia da existência da droga, nem o afilhado Gabriel. Estava guardando a droga para um traficante. Os guardas viram o afilhado com uma sacola na mão, a sacola que continha drogas. Acredita que ele pegou a droga para inocentá-lo.

Interrogado judicialmente, o réu Gabriel dos Santos, relatou que não mora no local, estava na casa apenas para alimentar seu cachorro. Não tem envolvimento com o tráfico de drogas. Autorizou a entrada dos guardas, bem como seu padrasto também forneceu a autorização.

Com efeito, os guardas municipais apresentaram versão firme, coerente e rica em detalhes demonstrando que o réu Joacir trazia consigo, em via pública, 02 (duas) porções de maconha destinados a comercialização. Além disso, na residência localizada na Rua Acácio Rodrigues de Moraes, nº 675, Jardim Saltense, os réus guardavam e tinham em depósito diversos tipos de entorpecentes (crack, cocaína e maconha), embalados e prontos para comercialização. No quarto de Joacir foram apreendidas três porções de maconha, Gabriel, foi visto dispensando no chão um embrulho plástico de cor preta contendo entorpecentes e Amanda confessou que havia mais entorpecentes no banheiro, tendo sido recolhidos mais 03 (três) pacotes contendo diversas porções de maconha.

Além disso, Joacir confessou os fatos ao dizer que executou a atividade típica "manter em depósito", além disso, apontou que Gabriel estava na posse da sacola com

drogas no momento em que os guardas chegaram (mesma versão dos guardas municipais), o que demonstra que Gabriel sabia da existência e localização das drogas na casa, sendo que a quantidade e variedade dos entorpecentes, além da existência de balança, papel filme e rádios comunicadores, demonstram a prática do tráfico pelos envolvidos.

Finalmente, não há qualquer indício de prova que autorize concluir que os guardas tenham mentido para prejudicar os réus. As declarações de policiais e guardas municipais possuem relevância e autorizam a condenação, quando isentos de má-fé ou suspeição, e apoiados nos demais elementos de prova, como na hipótese. Nesse sentido tem-se a jurisprudência do E. Tribunal de Justiça de São Paulo:

"As declarações dos agentes estatais, a princípio, são isentas de suspeita e só não possuem valor quando estes agem de má-fé, o que não é o caso. Desta forma, inexistindo circunstâncias que afastem a eficácia probatória do depoimento dos policiais e considerando que suas declarações foram ratificadas em juízo, mister é o reconhecimento do seu valor probante (Ap. Crim. (Réu Preso) n. 2010.079995-7, de Jaraguá do Sul, rela. Desa. Salete Silva Sommariva)."

Tráfico ilícito de entorpecentes. Preliminares afastadas. Ilicitude de provas por terem sido obtidas por guardas civis municipais não constatada. Inteligência do artigo 144, § 8º, da CF, regulamentado pela Lei 13.022/2014, em interpretação conjunta com o artigo 301, do Código de Processo Penal. Preliminar de nulidade por violação de domicílio. Não ocorrência. Existência de fundada suspeita apta a justificar o ingresso no imóvel. Réu flagrado ao sair de ponto conhecido de comércio espúrio, sendo abordado e apreendido em seu poder a quantia injustificada de R\$ 40,00. Em incursão por viela próxima ao local, os agentes estatais, após iluminarem o imóvel que estava com a porta aberta, avistaram uma sacola preta, contendo, em seu interior, 65 porções de cocaína, com massa líquida de 26,62 gramas, e 90 porções de maconha, com peso líquido de 220,67 gramas. Cômulo pertencente ao acusado. Violação não constatada. Entendimento pacificado pelo STF em repercussão geral (tema 280). Pleito absolutório Impossibilidade. Autoria e materialidade comprovadas. Depoimentos firmes e coerentes prestados pelos guardas municipais. Negativa do réu isolada. Tráfico evidenciado. Condenação mantida. Reforma das penas. Bases indevidamente fixadas acima dos mínimos legais, por ocasião da quantidade de droga. Volume que não justifica maior reprovabilidade da conduta. Acusado primário e possuidor de bons antecedentes. Exclusão da agravante da calamidade pública. Aplicação do redutor à fração máxima. Penas finalizadas em 1 ano e 8 meses de reclusão e 166 dias-multa. Regime aberto e substituição da pena privativa de liberdade. Parcial provimento ao apelo. (TJSP; Apelação Criminal 1503301-54.2020.8.26.0526; Relator (a): Guilherme de Souza Nucci; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Salto - 2ª Vara; Data do Julgamento: 14/12/2021; Data de Registro: 14/12/2021).

Relevante destacar ainda que, conforme laudo pericial de extração de dados realizados às fls. 222-379, foram encontradas no celular Motorola Moto G60 diversas conversas compatíveis com a venda de drogas. Através do aplicativo Facebook Messenger: "Cinthia Ribeiro: Eaii. Ta tendo Beck? Amanda Ribeiro: Só 25g. Cinthia Ribeiro: Pagamento só a vista? Amanda Ribeiro: Então a prazo 120\$. (fls. 233-234). Ainda, pode-se observar às fls. 277 o contato registrado como Família Ribeiro, de número de linha 5511943472730 criou um grupo "Anotações" com o contato registrado como "Pai", de número de linha 11-998660108, removendo-o na sequência, utilizado posteriormente, para apontamentos de nomes e valores, tais como: "Amanda dia 26 - pago 120\$. Gisele dia 05 - 120\$, Adrian dia 05 - 120\$, Wesley dia 27 - 120\$ pago, Wesley dia 03 - 120\$, Jhow dia 26 - 120\$ pago, Resumo C.S.J, Kit 28 pago" (fls. 277-278). No celular Motorola XT2053-2XT2053-2, da mesma maneira, foram identificadas conversas compatíveis com o tráfico de drogas, como por exemplo: "Bryan: Tem verde?. Amanda Ribeiro: Salve. Tem. Bryan: Dmr. Amanda Ribeiro: Encosta. Bryan Pdp to indo. Amanda Ribeiro: ok". Além das conversas descritas, dentre as mídias obtidas da extração de dados, foram encontradas imagens com vinculação à natureza delitiva em questão (foto de pesagem de entorpecentes, entorpecentes embalados vide fls. 227-228, 354). Em que pese a negativa de autoria do delito de tráfico de drogas pelos réus, certo

é que as circunstâncias da prisão, aliadas a apreensão de objetos comumente utilizados na prática do tráfico, extração de dados de dois celulares apreendidos com conversas compatíveis com o tráfico de drogas, denotam o intuito mercantil e, corroborados pelos demais depoimentos colhidos, são suficientes a embasar o decreto condenatório.

Com relação ao crime de associação para o tráfico, não há prova suficiente para a condenação dos acusados. A associação criminosa é um delito autônomo. Para que alguém responda por este crime são necessários os seguintes elementos: a) duas ou mais pessoas; b) acordo dos parceiros; c) vínculo associativo; d) finalidade de traficar tóxicos.

No caso dos autos restou demonstrada a prática do tráfico mas não ficou configurado o animus associativo, o dolo, ou seja, a vontade de se associar. A denúncia não narrou o modo nem o momento em que teria se estabelecido o vínculo associativo entre os acusados, com características de estabilidade e permanência. Além disso, reitero que não houve a realização de qualquer procedimento investigativo prévio, nem prova sob a égide do contraditório, que demonstrasse um mínimo de organização e planejamento para a prática da associação criminosa, sendo a prisão efetuada pela guarda municipal. Nesse sentido:

"AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DA IMPUTAÇÃO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PROVA INSUFICIENTE DA ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA DO VÍNCULO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO INVIÁVEL. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. APLICAÇÃO IMPOSSÍVEL. DEDICAÇÃO DOS PACIENTES À ATIVIDADE CRIMINOSA. CONDENAÇÃO SIMULTÂNEA POR ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Inicialmente, relembro que o habeas corpus não é a via adequada para apreciar pedido de absolvição pela prática do delito de associação para o tráfico, tendo em vista que, para se desconstituir o decidido pelas instâncias de origem, mostra-se necessário o reexame aprofundado dos fatos e das provas constantes dos autos, procedimento vedado pelos estreitos limites do remédio constitucional, caracterizado pelo rito célere e por não admitir dilação probatória. 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que a configuração do crime de associação para o tráfico de drogas (art. 35, da Lei n. 11.343/2006) exige a demonstração do elemento subjetivo do tipo específico, qual seja, o ânimo de associação de caráter duradouro e estável. Do contrário, o caso é de mero concurso de pessoas. 3. As instâncias ordinárias embasaram a condenação dos pacientes em elementos fáticos e probatórios concretos - com destaque para os depoimentos das testemunhas policiais -, os quais, detidamente examinados em primeiro e segundo graus de jurisdição, conduziram à conclusão de que os réus integrariam, de maneira estável e permanente, associação criminosa voltada à comercialização ilícita de entorpecentes. Assim, desconstituir tal entendimento, para absolver os pacientes, implicaria aprofundado reexame dos fatos e provas carreados aos autos, procedimento que é incompatível com a via estreita do habeas corpus. 4. No caso dos autos, não é possível a incidência da causa especial de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, pois a referida benesse não é aplicável a réus também condenados pelo crime de associação para o tráfico de drogas, tipificado no artigo 35, da Lei n. 11.343/2006, circunstância que denota, necessariamente, a sua dedicação à atividade criminosa. 5. Agravo desprovido. (STJ - AgRg no HC: 618503 RJ 2020/0267075-3, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 09/12/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/12/2020)",

Assim, a absolvição dos réus pelo crime de associação ao tráfico é medida que se impõe.

No tocante à dosimetria, tem-se que a condenação pelo artigo 28 da Lei de Drogas não gera reincidência, nesse rumo: "Viola o princípio da proporcionalidade a consideração de condenação anterior pelo delito do art. 28 da Lei nº 11.343/2006, "porte de droga para consumo pessoal", para fins de reincidência. STF. 2ª Turma. RHC 178512 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 22/3/2022 (Info 1048)."

O Plenário do STF, no julgamento dos habeas corpus nº 112.776 e nº 109.193, consolidou entendimento segundo o qual "configura ilegítimo bis in idem considerar

a natureza e a quantidade da substância ou do produto para se fixar a pena base (primeira etapa) e, simultaneamente, para a escolha da fração de redução a ser imposta na terceira etapa da dosimetria (§ 4º, do art. 33 da Lei 11.343/2006). Todavia, nada impede que essa circunstância seja considerada para incidir, alternativamente, na primeira etapa (pena-base) ou na terceira (fração de redução)". Importante salientar que as causas de diminuição de pena são mais relevantes que as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, de caráter nitidamente residual.

Portanto, se o juiz notar um fator de destaque no crime cometido pelo traficante primário, sem prova de que integre associação criminosa, como pequena quantidade da droga, deve utilizar esse critério para operar maior diminuição (ex.: dois terços), deixando de considerá-la para a fixação da pena-base. O contrário também se dá. Percebendo maior quantidade de drogas, ainda que em poder de traficante primário, de bons antecedentes, sem outras ligações com o crime organizado, pode reservar tal circunstância para a utilização na diminuição da pena.

Na hipótese analisada, a quantidade apreendida é considerável: a) 19 (dezenove) porções de "crack", com peso líquido de 2,81g b) 50 (cinquenta) porções de "cocaína", com peso líquido de 26,70g c) 201 (duzentas e uma) porções de "maconha", com peso líquido de 545,57g, os réus Amanda e Joacir são primários (fls. 204 e 208) e não restou provado que integram organização criminosa, considerando que a prisão decorreu de abordagem de guardas municipais sem qualquer investigação prévia; tudo a justificar a incidência da causa de diminuição em grau intermediário. Salientando-se que a quantidade de droga apreendida, por si só, não justifica o afastamento do redutor do tráfico privilegiado, sendo necessário, para tanto, a indicação de outros elementos ou circunstâncias capazes de demonstrar a habitualidade delitiva e participação em organização criminosa. Nesse sentido, tem-se a jurisprudência:

"AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INCIDÊNCIA. ABSORÇÃO DA CONDUTA RELATIVA AO ART. 33, § 1º, I PELA DO ART. 33, CAPUT, AMBOS DA LEI N. 11.343/2006. CONDUTA ÚNICA. CAFEÍNA UTILIZADA COMO MEIO DE OBTENÇÃO DA DROGA COMERCIALIZADA (COCAÍNA). APREENSÃO NO MESMO CONTEXTO FÁTICO. QUANTIDADE E NATUREZA DO ENTORPECENTE APREENDIDO. UTILIZAÇÃO PARA EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE E AFASTAMENTO DA MINORANTE. BIS IN IDEM. OCORRÊNCIA. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA. COMPROVAÇÃO DE DEDICAÇÃO DO AGENTE. ÚNICO FUNDAMENTO DECLINADO. APLICAÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A interposição concomitante de recursos tanto pelo Ministério Público Federal quanto pelo estadual não impede a análise da via de impugnação protocolada posteriormente; pois, de acordo com entendimento desta Corte," o Ministério Público Estadual possui legitimidade para a interposição de agravo regimental, ainda que o Parquet Federal tenha exercido essa faculdade com precedência, sem que configure preclusão consumativa ou violação ao princípio da unirrrecorribilidade "(EDcl no AgRg no Resp n. 1.843.259/R0, relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 23/6/2020, DJe 29/6/2020). 2. Sobre a aplicação do princípio da consunção, esta Corte entende que ele"incide quando for um dos crimes meio necessário ou usual para a preparação, execução ou mero exaurimento do delito final visado pelo agente, desde que não ofendidos bens jurídicos distintos. Entre os delitos de tráfico de drogas, de seus insumos ou maquinário, pode ocorrer a consunção quando constatado que sejam os insumos ou maquinários confirmados como meios de obtenção da droga comercializada"(HC n. 598.863/SC, relator Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 1º/9/2020, DJe 16/9/2020). 3. Na hipótese em exame, em que pese às instâncias ordinárias salientarem a existência de duas condutas autônomas, não é o caso, pois o armazenamento da cafeína constitui fato praticado no mesmo contexto do flagrante do paciente que portava os entorpecentes, tendo a Corte de origem destacado que" a cafeína seria utilizada para misturar à cocaína durante seu preparo, a fim de obter maior lucro na comercialização do entorpecente ". Assim sendo, deve ser afastada a incidência do crime previsto no art. 33, § 1º, I, da Lei 11.343/2006, ficando apenas o tipo penal do art. 33, caput, da mesma Lei. 4. Sendo a quantidade e a natureza das drogas apreendidas valoradas tanto para exasperar a pena-base quanto

para afastar aplicação da minorante do tráfico dito privilegiado, sendo o único fundamento apontado pela Corte de origem para rechaçar a redutora legal, verifica-se indevido bis in idem. Precedentes. 5. No julgamento do REsp n. 1.887.511/SP, de relatoria do Ministro João Otávio de Noronha, concluiu a Terceira Seção desta Casa que a quantidade de substância entorpecente e a sua natureza hão de ser consideradas na fixação da pena-base, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, não sendo, portanto, pressuposto para a incidência da causa especial de diminuição de pena descrita no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006. Com efeito, a quantidade e natureza do material tóxico somente poderão justificar o afastamento do benefício de forma supletiva, e quando o contexto em que se deu a sua apreensão evidenciar a dedicação à atividade criminosa. 6. No caso, as instâncias de origem não questionaram, em nenhum momento, a primariedade e os bons antecedentes do sentenciado, tampouco aludiram ser ele integrante de organização criminosa, a não ser por presumirem exclusivamente com base na quantidade das drogas apreendidas, o que não se admite. A dedicação à atividade criminosa foi assentada tão somente na quantidade de material tóxico encontrada no momento da prisão em flagrante. 7. Agravo regimental desprovido." (AgRg no HC 682.984/SC, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 22/10/2021).

Em se tratando de crime de tráfico de drogas, consoante artigo 63 da Lei nº11.343/2006, o perdimento de qualquer bem e valor apreendido nos autos, em favor do FUNAD, é efeito da condenação, na forma do artigo 91, caput, do Código Penal. Sobre o assunto, o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Tema 647 dar repercussão geral, por maioria, fixou a tese de que é possível o confisco de todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico de drogas, sem a necessidade de se perquirir a habitualidade, reiteração do uso do bem para tal finalidade, a sua modificação para dificultar a descoberta do local do acondicionamento da droga ou qualquer outro requisito além daqueles previstos expressamente no art. 243, parágrafo único, da Constituição Federal. (RE638491/PR, rel. Min. Luiz Fux, julgamento em 17/05/2017).

A Constituição Federal, em seu art. 243, parágrafo único, dispõe que todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins será confiscado e reverterá em benefício de instituições e pessoal especializados no tratamento e recuperação de viciados e no aparelhamento e custeio de atividades de fiscalização, controle, prevenção e repressão do crime de tráfico dessas substâncias

Dessa forma, considerando que compete ao réu a prova da origem lícita dos objetos e valores apreendidos (art. 60, § 1º, da Lei 11.343/2006), e, tendo em vista que os sentenciados não se desincumbiram do seu ônus, decreto o perdimento do celulares Motorola Moto G60, cor prata e preta, Motorola XT2053-2, cor azul e preta, Xiaomi M1908C3JG, cor azul e preta, Samsung SM-A015M, cor vermelha e preta, dos radios comunicadores marca Baofeng, modelo BF-888S e da quantia em dinheiro pertencentes aos réus, a ser revertidos ao FUNAD (art. 63, § 1º, da Lei nº11.343/2006).

Assim, satisfatoriamente comprovadas a materialidade e autoria do delito de tráfico de drogas, passo a dosagem das penas.

AMANDA DOS SANTOS RIBEIRO

Analisada as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, a ré é primária, culpabilidade, conduta social, personalidade do agente, motivos são normais à espécie, as circunstâncias e consequências do crime, não podem ser valorados negativamente, razão pela qual fixo a pena-base em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Na segunda fase, ausente agravantes e presente a atenuante da menoridade, mantenho a pena no mínimo legal, conforme súmula 231 do STJ.

Considerando a primariedade e o não envolvimento com nenhuma organização criminosa, com fundamento no §4º do art. 33 da Lei de Tóxicos, reduzo a pena em 1/3, obtendo a pena de 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 333 (trezentos e trinta e três) dias-multa.

Diante da quantidade de pena aplicada, o regime é o aberto (artigo 33, §2º, alínea 'c' e §3º, do Código Penal).

Atendidas as condições previstas no art. 44, incisos I a III, e art. 77, "caput",

inc. III, do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direito, consistentes na prestação de serviços à comunidade pelo mesmo prazo da pena original, a ser especificada em sede de execução penal e prestação pecuniária no valor de 01 (um) salário mínimo.

JOACIR DA SILVA RIBEIRO.

Analizada as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, a réa é primária, culpabilidade, conduta social, personalidade do agente, motivos são normais à espécie, as circunstâncias e consequências do crime, não podem ser valorados negativamente, razão pela qual fixo a pena-base em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Na segunda fase, sem agravantes e existente a atenuante da confissão, que não conduzir a pena abaixo do mínimo legal.

Considerando a primariedade e o não envolvimento do réu com nenhuma organização criminosa, com fundamento no §4º do art. 33 da Lei de Tóxicos, reduzo a pena em 1/3, obtendo a pena de 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 333 (trezentos e trinta e três) dias-multa.

Diante da quantidade de pena aplicada, o regime é o aberto (artigo 33, §2º, alínea 'c' e §3º, do Código Penal).

Atendidas as condições previstas no art. 44, incisos I a III, e art. 77, "caput", inc. III, do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direito, consistentes na prestação de serviços à comunidade pelo mesmo prazo da pena original, a ser especificada em sede de execução penal e prestação pecuniária no valor de 01 (um) salário mínimo.

GABRIEL DOS SANTOS

Analizada as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, o réu ostenta maus antecedentes que serão valorados como reincidência, culpabilidade, conduta social, personalidade do agente, motivos são normais à espécie, as circunstâncias e consequências do crime, não podem ser valorados negativamente, razão pela qual fixo a pena-base em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase da fixação da pena, ausentes atenuantes e presente a agravante da reincidência no tocante ao crime de roubo (fls. 213; (1500226-43.2018.8.26.0569) fixo a pena em

Ausentes causa de diminuição e aumento, torno definitiva a pena de 5 anos, 10 meses e 583 dias-multa dias-multa, no mínimo legal.

Diante da reincidência específica e sendo desfavoráveis as circunstâncias judiciais, o regime inicial será o fechado, conforme artigos 33 e 59, ambos do Código Penal.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito e incompatível com o benefício da suspensão da pena, uma vez que não preenchidos os requisitos do artigo 44 e do 77 a 82, todos do CP.

Ante o exposto, e considerando o mais que dos autos consta, julgo PROCEDENTE a pretensão punitiva do estatal para o fim de:

a) CONDENAR a ré AMANDA DOS SANTOS RIBEIRO, qualificada nos autos, por infração aos artigos 33, caput, da Lei nº 11.343/06, à pena de 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 333 (trezentos e trinta e três) dias-multa, no mínimo legal, em regime aberto, sendo a pena privativa de liberdade substituída por restritivas de direitos.

b) CONDENAR o réu JOACIR DA SILVA RIBEIRO, qualificado nos autos, por infração aos artigos 33, caput, da Lei nº 11.343/06, a pena de 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 333 (trezentos e trinta e três) dias-multa, no mínimo legal, em regime aberto, sendo a pena privativa de liberdade substituída por restritivas de direitos.

c) CONDENAR o réu GABRIEL DOS SANTOS, qualificado nos autos, por infração aos artigos 33, caput, da Lei nº 11.343/06 à pena de 5 anos, 10 meses e 583 dias-multa dias-multa, no mínimo legal, em regime fechado.

Considerando que o réu Gabriel dos Santos é reincidente específico, respondeu ao processo preso, há perigo concreto de reiteração delitiva, neg o direito de apelar em liberdade.

Concedo a interposição de recurso em liberdade aos réus Amanda dos Santos Ribeiro e

Joacir da Silva Ribeiro, diante da substituição da pena privativa de liberdade em restritiva de direito e regime aplicado. Expeça-se alvará de soltura clausulado. Decreto o perdimento do celulares Motorola Moto G60, cor prata e preta, Motorola XT2053-2, cor azul e preta, Xiaomi M1908C3JG, cor azul e preta, Samsung SM-A015M, cor vermelha e preta, dos rádios comunicadores marca Baofeng, modelo BF-888S e da quantia em dinheiro pertencentes aos réus, a ser revertidos ao FUNAD (art. 63, § 1º, da Lei nº11.343/2006).

Arcará o réu ainda com o pagamento das custas processuais (Lei Estadual n.º 11.608, de 29 de dezembro de 2003, artigo 4º, §9º, alínea "a"), com as ressalvas da lei de assistência judiciária, que ora lhe concedo. Após o trânsito em julgado: (i) comunique-se ao Juízo Eleitoral para as providências cabíveis, na forma do artigo 15, inciso III, da Constituição Federal; (ii) expeça-se a guia para execução, devendo a pena de multa ser cobrada nestes autos.

Oportunamente, ao arquivo.

Publique-se e intime(m)-se.

Salto, 22 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA